

LOS CONTRATOS INFORMÁTICOS

Denominamos "**contratos informáticos**" a todo convenio entre partes que tienen por objeto la prestación de bienes y/o servicios informáticos o que estén vinculados a la información automatizada.

Se entiende por "**bien informático**" a todos aquellos elementos que conforman el "sistema". Estos elementos son el "soporte físico" (el hardware, la unidad central de proceso, sus periféricos y todos los equipos que tengan una relación directa de uso con respecto a ellos) y el "soporte lógico" (bienes inmateriales que proporcionan órdenes, datos, procedimientos e instrucciones en el tratamiento automático de la información).

Por su parte, los "**servicios informáticos**" son todos aquellos servicios que sirven de apoyo y complemento a la actividad informática (capacitación de personal, consultoría o auditoría informática, etc.).

Clasificación de los Contratos Informáticos.

Para poder estudiar correctamente a los "contratos informáticos" vamos a clasificarlos en dos grandes grupos:

a) Grandes Contratos Informáticos a medida. En esta categoría nos referiremos a las características de un nuevo tipo de contrato, distinto a los conocidos en el derecho tradicional, con particularidades, regulaciones y obligaciones que le son propias y exclusivas. Estos contratos requieren de un meticuloso y prolijo análisis previo que demanda grandes cantidades de tiempo y de recursos humanos y económicos antes de lograr la rúbrica final.

b) Contratos Informáticos en particular. Se trata de contratos informáticos especiales (pueden ser pequeños, medianos o grandes) caracterizados por la posibilidad de contratarse en forma separada o también conjunta, bienes informáticos (hardware o software) o la prestación de algún servicio informático. Dependiendo de su complejidad, muchos de ellos tendrán varias de las características mencionadas de la Teoría General del Contrato Informático.

A) Grandes Contratos Informáticos a Medida.

Es muy probable que cualquier persona que conozca los aspectos generales del Derecho y que se acerque por primera vez a la temática del contrato informático, se vea tentada en sostener que estamos frente a cualquiera de las modalidades contractuales conocidas como ser un contrato de compraventa, de obra, de servicios, de licencia de uso, de leasing, etc. Pero esta afirmación es incorrecta pues, los “contratos informáticos” constituyen un nuevo tipo de contrato con características muy particulares que lo diferencian de todos los demás conocidos. Del mismo surgen grandes particularidades:

- **La enorme desigualdad existente entre el proveedor y el usuario de bienes y servicios informáticos respecto al conocimiento de la tecnología.** El proveedor es un especialista en la materia, conoce lo que está vendiendo y ofreciendo, conoce las virtudes de sus productos, pero también sus defectos y limitaciones, conoce el estado del arte y el nivel de obsolescencia de lo que se ofrece en el mercado. Por otro lado, tenemos al usuario que generalmente es un neófito en la materia o sus conocimientos tienen una lógica limitación y solo sabe que necesita incorporar instrumental informático a su organización a efectos de optimizar y/o modernizar su funcionamiento.
- **La alta complejidad del objeto a contratar.** Lo que hace dificultoso poder describir o redactar adecuadamente y en términos entendibles, las pretensiones de lo que se quiere contratar (el objeto) en el texto final. En estos casos debe actuar un abogado especializado en la redacción de contratos de esta complejidad con la habilidad de poder prevenir eventuales conflictos futuros y defender equitativamente los derechos de las partes.
- **Las condiciones abusivas impuestas por las grandes empresas informáticas.** El mercado internacional de tecnologías informáticas para los grandes clientes se caracteriza por su alto nivel de concentración (casi monopólico) de las grandes empresas de software que controlan casi la totalidad del mercado informático mundial. América Latina participa con un ínfimo porcentaje en el mismo. Esto genera un ahondamiento y una disparidad de la brecha tecnológica entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. De esta forma estas grandes empresas se permiten imponer determinadas condiciones arbitrarias y abusivas en los contratos informáticos a las que nuestro derecho debe darle respuestas adecuadas para lograr equiparar a las partes.

Teoría General del Contrato Informático.

La "Teoría General del Contrato Informático" se refiere al esquema o a la "parte general" de los aspectos comunes que poseen los grandes contratos informáticos a medida donde, luego de considerables esfuerzos y tiempo de negociación, el objeto final a contratar son tanto bienes como servicios informáticos. En conclusión, antes de encarar la negociación de un contrato informático se deberá tener pleno conocimiento de:

1. El concepto de "Sistema"
2. El moderno concepto de "entrega" del sistema
3. El Test de Aceptación
4. Las "Obligaciones Específicas" de la contratación informática y
5. La Etapa Precontractual y su Documentación.

1. El concepto de "Sistema". Un "sistema" es un conjunto de individualidades interrelacionadas entre sí, en donde cada individualidad forma parte del todo y, por lo tanto, si llegase a faltar o fallar alguna de esas individualidades, se resiente o afecta el todo.

Siempre que contratamos bienes y servicios informáticos, estamos frente a la contratación de un "sistema". Esto tiene vinculación con la "garantía de compatibilidad" y la "garantía de modularidad" de los distintos componentes del sistema.

Al contratarse un "sistema", ningún elemento se contrata como elemento separado, sino que necesariamente se contrata para que funcione en el marco de un sistema determinado. Entonces, cuando hablamos de contratar un "sistema" informático, nos referimos en su conjunto a:

- **Bienes informáticos:** Soporte físico (hardware) y soporte lógico del sistema (software).
- **Servicios informáticos:** Asistencia técnica, capacitación o formación técnica del personal del usuario, mantenimiento del sistema, actualizaciones, documentación respaldatoria, etc.

2. El moderno concepto de "entrega" del sistema. En la mayoría de los contratos, luego de abonar por algo que adquirimos, la simple entrega (o "tradición") de la cosa contratada hace concluir ("perfecciona") el contrato pasando la titularidad del dominio del vendedor al comprador. Ej. al comprar una revista, automáticamente paso a ser el dueño de la misma (se concluye el contrato) cuando pago el precio y me hacen la entrega física de la cosa.

En la contratación informática este principio es muy diferente, debido a que al adquirente de un sistema informático no le alcanza con que le hagan la "entrega física" de un conjunto de cajas conteniendo los diferentes elementos que componen el sistema, sino que tienen que producirse indefectiblemente una serie de hechos posteriores.

En primer lugar, al momento de recepcionarse físicamente el sistema, el usuario suscribe lo que se denomina el "Acta de Recepción Provisoria" del Sistema. Acto seguido va a necesitar instalar ese sistema en su servidor y/o en sus máquinas para finalmente realizar un tercer y anteúltimo paso que es la puesta en marcha del mismo, esto es, iniciarlo o ponerlo en funcionamiento por primera vez.

Una vez que el sistema fue entregado "provisoriamente", instalado y puesto en marcha, comienza inmediatamente la última instancia de la "entrega" denominada "Test de Aceptación", es decir, un periodo de prueba de 30, 60 o 90 días en donde el sistema se testea exhaustivamente a fin de analizar si el mismo opera normalmente y si responde a las necesidades para las cuales fue desarrollado.

3. El Test de Aceptación. Al recepcionarse físicamente el sistema se suscribe lo que se denomina el "Acta de Recepción Provisoria" del Sistema y se establece el momento de inicio del período del Test de Aceptación.

En el contrato se deberán necesariamente definir cuáles son los aspectos, los niveles y los ítems o componentes del sistema que van a ser evaluados durante el Test de Aceptación. Es decir, no es una evaluación global ni subjetiva del adquirente de ese sistema, sino que en el mismo contrato se deben definir:

- Los ítems a evaluarse durante el período del Test de Aceptación.
- Los valores estimados que respondan en cada ítem a los estándares propuestos en la oferta y requeridos en la demanda de contratación.
- Cómo se va a medir el cumplimiento de esos estándares y quiénes van a ser los encargados de hacerlo.

Esto significa que en el contrato se deberán elaborar grillas (generalmente en una escala de 1 a 10) en las que tendrán que figurar los ítems que van a ser evaluados y en donde se establezca la escala de merituación de cada uno de esos ítems y la forma en definitiva de calificación, para así poder evaluar si el sistema responde adecuadamente a los parámetros o estándares establecidos. Esto va a permitir ir evaluando ítem por ítem, respondiendo objetivamente a los valores especificados en la planilla o en la grilla de evaluación y así evitar problemas de interpretación.

Una vez concluido todo el proceso de testeo, y en la medida en que el sistema haya respondido adecuadamente a los estándares propuestos en la oferta y descriptos en el “cuadro de necesidades” que haya elaborado el usuario, se suscribe el "Acta de Recepción Definitiva del Sistema". Recién aquí el sistema pasa al dominio del usuario por lo que recién en esta instancia estaremos en condiciones de afirmar que el mismo fue efectiva y jurídicamente "entregado".

4. Obligaciones específicas de la contratación informática. Todos los contratos son fuentes de obligaciones. La razón de ser de un contrato es justamente la creación de un vínculo de derechos y obligaciones entre dos o más partes sometidas al mismo. También existen las “obligaciones extracontractuales” que son aquellas que no tienen origen en un contrato, sino que, por ejemplo, se originan o son generadas por una ley que es una fuente inmediata de obligaciones.

Pero independientemente de ello, en las contrataciones informáticas existen además “obligaciones específicas” que difícilmente sean obligatorias en otro tipo de contratos.

A modo de ejemplo, las “obligaciones específicas” más relevantes en la contratación informática son:

- **Obligación de Consejo o Asesoramiento (del proveedor al usuario):** Inicialmente, el usuario deberá proporcionarle al proveedor un informe detallado (denominado “Cuadro de Necesidades”) sobre las características de la empresa u organización y sobre las razones esgrimidas para modernizarla con nuevo instrumental informático. Seguidamente, el proveedor deberá realizar un meticuloso análisis de dicha información y tendrá la obligación de aconsejar de la mejor manera al usuario sobre cuáles pueden ser las respuestas informáticas más adecuadas y beneficiosas para su organización, e inclusive aconsejarlo si es realmente necesario tomar la decisión de informatizar. Ésta obligación está fundada en el desequilibrio de conocimientos tecnológicos que existen entre ambas partes que mencionamos al comienzo. No alcanza con que el proveedor elabore una simple respuesta a los requerimientos del usuario, sino que deberá evaluar esos requerimientos y aconsejar al usuario sobre la solución tecnológica más adecuada a sus necesidades.

- **Obligación de Advertencia (del proveedor al usuario):** Nuestro derecho considera a la informática y a los bienes informáticos como “cosas peligrosas”, debiendo quien los provee advertirle al usuario acerca de todas las consecuencias negativas que generará el uso o implementación del moderno instrumental informático. Ubicada en cabeza del proveedor de bienes y servicios informáticos, pone a su cargo la obligación de advertir al usuario los fuertes cambios culturales y los riesgos que la incorporación de la solución informática propuesta implicaría para el proyecto, para la organización, para los empleados y para el propio usuario. Esto es así puesto que todo proceso de informatización

importa un importante trauma en la organización que suele reflejarse en el periodo en que el viejo y el nuevo sistema tienen que funcionar en forma paralela generando malestares, capacitación adicional, horas extras, eventual liberación de personal, eventuales riesgos desde el punto de vista tributario, etc., incluso advertir sobre los cambios técnicos y/o organizativos que se deberán implementar en la organización cuando el nuevo sistema esté definitivamente en funcionamiento.

- **Obligación de Colaboración (de ambos):** Si bien en todos los contratos bilaterales, las partes necesariamente tienen que colaborar para que puedan cumplir adecuadamente las distintas obligaciones, ésta obligación también asume características particulares en la contratación informática ya que la no colaboración de alguna de ellas haría en muchas circunstancias imposible para la otra el cumplimiento de su obligación. Ambas partes deben estar a total disposición para garantizar que la otra pueda dar cumplimiento a las obligaciones asumidas contractualmente.

5. La Etapa Precontractual. Es aquella que se inicia desde el momento en que el usuario identifica la necesidad de adquirir bienes y servicios informáticos en su empresa u organización hasta la adjudicación del contrato a un proveedor determinado.

Es un muy largo y complejo período de tiempo que puede durar muchos meses y que comprende desde el primer contacto entre el usuario con el proveedor hasta la firma final del contrato de bienes y servicios informáticos.

Durante la misma se llevan a cabo toda clase de tratativas, se definen las necesidades del usuario y comienzan a ser exigibles las obligaciones específicas mencionadas.

Es un momento de particular importancia pues sirve para documentar cómo se construyó paulatinamente el acuerdo de voluntades, y para acumular elementos probatorios que acrediten estas circunstancias en caso de un conflicto posterior.

Un buen contrato informático se caracteriza particularmente por incorporar en su texto toda la documentación suscripta en la etapa precontractual para así retrotraer las obligaciones específicas de las partes también al comienzo de las negociaciones. Por otro lado, en la etapa precontractual el proveedor deberá hacer efectiva su obligación de consejo, de colaboración y de advertencia.

Quiere decir que, antes de la suscripción del contrato final, existe un largo y continuado proceso de análisis y colaboración que debe ser adecuadamente documentado mediante documentos especiales que deberán incorporarse al contenido del instrumento general del contrato definitivo.

Suspensión intempestiva de las negociaciones. En la precontractualidad de bienes y servicios informáticos, existen tanto por parte del usuario adquirente, como del proveedor, enormes

inversiones de tiempo, esfuerzo, dinero, organización, afectación de recursos humanos y aprovechamiento o no de otras oportunidades de negocios.

Por ello, si bien nuestra Constitución Nacional establece el principio de “libertad de contratación” donde cada persona puede contratar con quien desee, en estos contratos en particular ninguna parte puede suspender intempestivamente las negociaciones precontractuales avanzadas sin una causa que efectivamente la fundamente y/o justifique. Caso contrario correrá el certero riesgo de pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez de acuerdo al tiempo y recursos que se utilizaron.

Si bien en la mayoría de los contratos se libera a quien participa de negociaciones precontractuales de la obligación de suscribir efectivamente el contrato definitivo con algún proveedor, en el caso de la contratación informática debido a la alta complejidad del objeto a contratar y al tiempo, dinero y recursos invertidos, esta posibilidad se reduce considerablemente.

La Documentación en la Etapa Precontractual. En la Etapa Precontractual habrá que ir incorporando y ordenando prolijamente un conjunto diferenciado y complejo de documentación que, en definitiva, permita, en el momento de plantearse un eventual conflicto futuro, poder recurrir a esa información correctamente documentada para desentrañar cuál fue la verdadera voluntad de las partes y cuál fue el contenido de los compromisos que se fueron asumiendo durante el desarrollo de las negociaciones.

Todo ello a efectos de poder evaluar y definir cuestiones vinculadas a la responsabilidad civil y específicamente al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de las partes.

Pero para poder realizar una correcta tarea de documentación a efectos de incorporarla de manera prolija al futuro contrato informático, es necesario definir cuáles son los documentos más relevantes que deberán necesariamente ser suscriptos entre las partes durante el proceso precontractual:

- **El "Cuadro de Necesidades".** Es el primer documento precontractual, donde el usuario describe las características generales y particulares de su empresa u organización, justifica la toma de la decisión de incorporar el instrumental informático y además detecta el conjunto de las necesidades que, a su criterio, se resuelven con dicho instrumental informático. Este documento deberá ser entregado al proveedor para que pueda realizar un primer análisis de la situación y comenzar a aconsejar al usuario.
- **El "Acuerdo Marco" o "Carta de Intención".** Luego que el proveedor analizó el “Cuadro de Necesidades”, y se estableció un primer vínculo entre las partes para trabajar conjuntamente, suscribirán un “Acuerdo Marco” en el que expresarán su intención de participar de las negociaciones

que vayan elaborando un proyecto que permita la efectivización definitiva del contrato informático a largo plazo.

El proveedor, antes de elaborar la Oferta final (que es el último documento que se suscribe), tendrá que verificar si el contenido del "Cuadro de Necesidades" elaborado por el usuario es acertado. Si no lo considera así, tendrá la obligación de aconsejar al usuario acerca de las modificaciones a introducirse tanto en la descripción de la organización, en la valoración de la oportunidad, como en la detección de lo que el usuario considera son las necesidades a resolver.

En este "Acuerdo Marco" ya se establecen una serie de compromisos y obligaciones para las partes, como son por ejemplo las "cláusulas de confidencialidad", debido a que el proveedor va a acceder a un conjunto de datos que tienen que ver con la competencia, con el mercado, con la descripción de la organización, con las perspectivas de crecimiento y desarrollo de la misma, etc., que exigen necesariamente adoptar este tipo de compromisos.

- **Las "Actas Intermedias"**. Es de sana política contractual que en cada una de las reuniones en las que se evalúa la marcha del proceso a lo largo de la etapa precontractual, se vayan suscribiendo pequeñas actas firmadas por todos los participantes de las mismas y donde se asienten todas las modificaciones que se vayan incorporando al "Cuadro de Necesidades" inicial. Es decir, una persona toma nota o acta de los asistentes a la reunión, de los temas a tratar y de todo lo conversado y decidido. Luego los presentes firman dicha acta a fin de que no quede ningún dicho, acuerdo o afirmación librado al azar o a la libre interpretación futura.

- **Las "Actas de Avance"**. En dichas actas se van estableciendo los "Cronogramas de Ejecución" de las distintas etapas del proceso hasta llegar a la firma definitiva del contrato. Estos "Cronogramas de Ejecución" son de suma importancia porque le permiten a las partes poder proyectar los trabajos en un cierto período de tiempo, y le posibilitan al usuario poder ejercer la facultad de evaluar las propuestas de otro proveedor, ya que, si durante el largo período de la etapa precontractual el usuario solo trabaja con la oferta de uno solo, está perdiendo una oportunidad comparativa de recorrer el mismo camino con otros proveedores. De esta forma se previene ante la eventual ruptura intempestiva de las negociaciones contractuales por parte de un proveedor.

- **La Oferta**. Finalmente, una vez concluida toda la etapa precontractual en la que se procuró establecer y documentar con la mayor precisión y detalle posible la oferta final, las partes deberán suscribir un último documento donde conste la oferta formal por parte del proveedor y la aceptación de la oferta por parte del usuario. ***Aquí es donde se suscribe el contrato de bienes y servicios informáticos.***

La Responsabilidad Civil en la Etapa Precontractual.

La "responsabilidad civil" consiste en la obligación que recae sobre una persona "responsable" de reparar el daño "civil" que ha causado a otra persona, normalmente mediante el pago de una indemnización por daños y perjuicios.

Para evaluar si alguna de las partes es "civilmente responsable" durante la Etapa Precontractual, habrá que analizar previamente:

- Si la Etapa Precontractual se desarrolló adecuadamente y si se documentaron todas sus etapas.
- Si el usuario, en el "cuadro de necesidades" que le entregó al proveedor, describió adecuadamente su organización, si evaluó la conveniencia de incorporar instrumental informático nuevo y si analizó cómo dicho instrumental informático podía optimizar el funcionamiento de la organización según su criterio.
- Si el proveedor efectivamente dio cumplimiento a las obligaciones de consejo, colaboración y advertencia.

B) Contratos Informáticos en Particular.

En esta categoría incluiremos a aquellos contratos informáticos cuyo objeto puede ser tanto un bien informático (hardware o software) o la prestación de algún servicio informático en particular. Éstos son generalmente contratos pequeños y medianos, aunque en algunos casos existe la posibilidad de que se trate de contratos de mayor envergadura (ej. desarrollo de software a medida) en donde incluso, dependiendo de su complejidad, se deberán tener en cuenta varias de los aspectos mencionados en la Teoría General del Contrato Informático, sobre todo lo relacionado con la etapa precontractual, la entrega, el Test de Aceptación y las obligaciones específicas.

Los "Contratos de Adhesión" y los "Contratos Informáticos". En esta categoría de contratos es muy frecuente encontrarnos frente a los ya mencionados "contratos de adhesión".

Un "contrato de adhesión" es un tipo de contrato cuyas cláusulas son redactadas e impuestas por una sola de las partes (el proveedor), con lo cual la otra (el usuario) no puede negociarlas y se limita tan sólo a aceptar (adherir) o rechazar el contrato en su integridad.

Ejemplos claros de contratos de adhesión, además de algunos contratos informáticos menores que ofrezcan bienes o servicios limitados y/o determinados y la gran mayoría de los telemáticos (Ej. contratación de una casilla de correo electrónico), son los contratos de suministro de servicios públicos (electricidad, agua corriente, gas, telefonía, etc.), servicios privados (Internet, telefonía celular, etc.) o la mayoría de los contratos de seguro y contratos bancarios.

En estos casos, la empresa que vende el bien o presta el servicio ofrece el mismo a través de un contrato innegociable, y el consumidor debe elegir entre aceptar el bien con todas sus cláusulas o no hacerlo. Esto ha planteado muchos problemas jurídicos, que en general se han ido encarrilando a través de distintas soluciones:

- En general se admite que el contrato de adhesión es válido y necesario. Sin embargo, se tiene en cuenta la especial debilidad del consumidor, a quien se lo protege por otras vías (legal, jurisprudencial, etc.).
- Las vías a través de las cuales se protege al consumidor son mediante la prohibición de las cláusulas abusivas, que son nulas de pleno Derecho, y a través de la vigilancia por las instituciones públicas de la actuación de las empresas.

CLASIFICACIÓN.

A continuación, se detalla una clasificación propuesta de los contratos informáticos especiales a los efectos de poder ubicarlos de acuerdo al objeto de la contratación.

La misma se basa en categorizar a los contratos en aquellos cuyo objeto son, por un lado, bienes informáticos y, por otro, servicios informáticos.

A) CONTRATOS CUYO OBJETO SON LOS BIENES INFORMÁTICOS.

Contrato de compraventa de hardware.

El hardware tiene que responder a los estándares de funcionamiento y eficiencia del sistema. Aquí será necesaria la obligación de consejo, de advertencia y de colaboración. Además, se van a incorporar *dos garantías específicas: la garantía de compatibilidad y la de modularidad*. El hardware debe ser necesariamente compatible con el resto del sistema y el proveedor tiene la obligación (relacionado con la obligación de consejo) de no sobre vender ni vender menos de lo que en realidad necesita el usuario, debiendo tener en cuenta cuál es el proyecto de desarrollo de su organización, para evitar la rápida obsolescencia del hardware que se está incorporando.

Contrato de locación o arrendamiento de hardware.

Se trata de la locación de hardware por un tiempo determinado y a cambio de un canon (precio) abonado por el usuario.

1. El concepto de sistema: El objeto del contrato es la entrega de la cosa y la obligación de garantía del locador del uso continuado y pacífico de la cosa durante el tiempo de vigencia del contrato. Se alquila el hardware a efectos de la utilización en el ámbito de un sistema informático determinado, y por ello se aplican la "garantía de compatibilidad" y la de "modularidad", temas que debemos tener presentes en la negociación y en la redacción de los contratos.

2. La etapa precontractual: Es necesaria la descripción del sistema en el cual va a funcionar el hardware por parte del usuario en el "cuadro de necesidades". El proveedor va a tener las obligaciones de consejo y de advertencia.

3. El moderno concepto de entrega: Determina el momento de inicio del plazo contractual establecido para este contrato y hacen nacer para el proveedor la "obligación de mantenimiento" y para el usuario la "obligación del pago" del canon.

4. El test de aceptación: Deberá efectivizarse en los contratos de locación ese período de 30 o 60 días durante el cual el hardware operará en el marco del sistema de acuerdo a los estándares ofrecidos por el locador en el momento de responder al requerimiento del usuario.

Contrato de mantenimiento de hardware.

El contrato de mantenimiento es una "obligación de resultado" que se considera incorporada a las obligaciones del locador en el contrato de locación de hardware. Esto implica que en el contrato habrá que especificar las características que deberán tener tanto el mantenimiento preventivo como el mantenimiento de urgencia.

Contrato de Software

El soporte lógico (software) permite que la computadora responda a las distintas necesidades operativas de las tareas que se están planteando. El software, por su naturaleza, tiene características especiales, instrumentales e intangibles. Es uno de los elementos esenciales del sistema, junto con el hardware y los periféricos, para que así pueda funcionar la "garantía de compatibilidad" y la "garantía de modularidad".

Es importante diferenciar entre dos grandes tipos de programas de computación:

- Sistema operativo: Permite la operación del sistema. Está orientado a que la computadora pueda funcionar y dar respuesta a los requerimientos que cada programa aplicativo incorpora.
- Sistema aplicativo: Es el que resuelve algunas tareas específicas (ej. procesadores de texto como el Word, planillas de cálculo como el Excel, desarrollos específicos a medida, etc.).

Contrato de compraventa de software enlatado o comercializado.

Es el software incorporado al mercado masivo, como un producto más en comercios de informática. Esto hace que no exista una relación directa entre el proveedor y el usuario, ya que el dueño del comercio (un tercero) es el que trata con el usuario. Es por ello que suelen existir problemas en el asesoramiento y en la negociación. Pasa lo mismo con la compra de una PC en un comercio, lo que

impide que jueguen los elementos de la teoría general del contrato informático (el test de aceptación, el moderno concepto de entrega, etc.).

Contrato de desarrollo de software a medida.

El proveedor se obliga a desarrollar un software determinado a la medida de las necesidades del cliente. Es muy difícil desarrollarlo si no hay cumplimiento efectivo de la obligación de colaboración entre las partes, de la obligación de consejo por parte del proveedor del software y de la obligación de advertencia. En la negociación y en la redacción de estos contratos, deben tenerse en cuenta la incorporación del moderno concepto de entrega, el test de aceptación, las obligaciones específicas y los derechos intelectuales y de propiedad.

La propiedad intelectual del software desarrollado a medida (como protección jurídica de los derechos de autor) va a depender de lo que decidan las partes a la hora de contratar y también de la actividad específica para el que fue desarrollado, pudiendo ser tanto del adquirente, del programador o mixto. De todos modos, generalmente es el adquirente el que exige en el contrato que el software esté a su nombre.

Contrato de licencia de uso de software.

El software licenciado no se desarrolla a medida del usuario, sino que en realidad tiene las características del software enlatado, pero de mayor complejidad.

Su comercialización masiva permite la baja razonable de su costo y de su desarrollo y, por ende, de su precio. El usuario tendrá la licencia exclusiva de uso y goce del software, pero con ciertas limitaciones a un número determinado de puestos de trabajo o por un tiempo determinado.

La Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723 establece dos niveles de responsabilidad para quien viole los derechos de propiedad intelectual sobre el software:

1. la responsabilidad patrimonial para la organización, con fundamento en los eventuales daños producidos al productor de un programa de computación, y
2. la responsabilidad penal (el art. 72 agrega el art. 171 al Código Penal) para el gestor de esa organización que ha violado en su funcionamiento los principios establecidos en la norma.

Contrato de licencia de uso de código fuente.

El código fuente es el corazón de un programa de computación y es la única forma que existe de acceder al contenido del desarrollo de un software.

La contratación del software tiene una problemática especial en función de la complejidad del software, que es una obra intelectual de características especiales que requiere, para su mantenimiento, el acceso al código fuente. El mismo tiene determinadas características especiales

que hacen que, desde el derecho, se requieran respuestas adecuadas en el ámbito contractual a efectos de restablecer el equilibrio entre las partes contratantes.

El código fuente está directamente vinculado a:

1. la propiedad: El propietario de un software tiene derecho a acceder, actualizar y modificar el código fuente de acuerdo a sus necesidades.

2. el mantenimiento: El usuario de un software tiene que tener, durante la vigencia del contrato, la garantía de poder mantenerlo, actualizarlo y modificarlo.

Es por ello que en los textos contractuales es aconsejable especificar la transferencia del código fuente en caso de transferirse la propiedad del software, y garantizar el mantenimiento, en caso de no transferirse la propiedad.

Contrato de llave en mano.

El contrato "llave en mano" o "turnkey contract" es aquel en que el contratista se obliga frente al cliente, a cambio de un precio, generalmente alzado, a concebir, construir y poner en funcionamiento una obra determinada que él mismo previamente ha proyectado. En este tipo de contrato el énfasis ha de ponerse en la responsabilidad global que asume el contratista frente al cliente.

Otras prestaciones que siempre están presentes en los contratos "llave en mano" son: el suministro de materiales y maquinaria; el transporte de los mismos; la realización de las obras civiles; la instalación y montaje, y la puesta a punto y en funcionamiento de la obra proyectada. En determinados casos, también es posible incluir en este tipo de contrato otras obligaciones posteriores a la ejecución de la obra, como la formación de personal y la asistencia técnica.

Otros contratos:

- Contrato de implementación de una infraestructura de Firma Digital.
- Contrato de implementación y mantenimiento de Intranet.

B) CONTRATOS CUYO OBJETO SON LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS.

Contrato de Outsourcing de bienes y servicios informáticos.

Este contrato implica la tercerización de todos aquellos sistemas o elementos secundarios ajenos al objeto principal de una empresa. Así se obtienen beneficios que están orientados a optimizar el funcionamiento de la organización, en la medida que cada uno de estos servicios tercerizados se encuentran en manos de un tercero que tiene los mejores niveles tecnológicos y humanos (por ej., empresas cuyo objeto central sea el almacenamiento de stock, el procesamiento de información, o el transporte de mercadería).

Así, en este contrato, las organizaciones tercerizan el tratamiento electrónico de su información a través del pago de un canon mensual previamente establecido. Pero esta actividad tiene implicancias concretas en cuanto a la capacitación del personal, al acceso a la información, a la confidencialidad, a la seguridad y al tipo de recursos humanos que van a participar y acceder a dicha información.

Contrato de mantenimiento de Sistemas de Información.

Tiene por fin asegurar el funcionamiento del sistema durante todo el término de vigencia de la relación contractual. El funcionamiento y la prestación de los servicios de sistematización y tratamiento de la información, requieren un adecuado diseño del contrato que garantice el funcionamiento del sistema y su correcto mantenimiento.

El mantenimiento de los sistemas de información no es una idea exclusiva de los componentes de un sistema informático, sino que, en realidad, todos aquellos elementos que al margen de la informática tienen un alto contenido de sofisticación tecnológica, necesariamente requieren de un adecuado mantenimiento y, en consecuencia, de la elaboración de contratos específicos.

Contrato de Escrow.

Cuando una empresa adquiere una licencia de uso de software, es conveniente prevenirse en el caso de que la empresa que lo desarrolla desaparezca. Por ello es frecuente que en el contrato de licencia de uso de software se incluya la denominada cláusula escrow, la cual confiere al usuario el derecho de acceder a una copia del código fuente y asegurándole así un uso futuro del software.

Normalmente, lo que se pacta es que el licenciatario (cliente/adquirente) podrá recuperar el código fuente del programa en caso de quiebra, suspensión de pagos o concurso de acreedores, disolución o liquidación del programador, de incumplimiento de la obligación de mantenimiento del software o para el caso de que la empresa desarrolladora del software transmitiera los derechos de propiedad intelectual sobre el programa a un tercero, o bien fuera privada de ellos por sentencia judicial.

En cuanto al contrato de Escrow, puede llevarse a la práctica ante un escribano o incluso nombrarse depositario al licenciatario o bien lo habitual, es constituirlo ante un profesional especializado (llamado Escrow Agent) que tenga las correspondientes medidas de seguridad física en sus locales. Es en un contrato tripartito.

Contrato de Hosting.

Es un contrato en virtud del cual una empresa provee una fracción de espacio en un servidor o host, para almacenar contenidos accesibles vía web. Los Web Hosting son compañías que proporcionan este servicio a sus clientes. Por lo general se pueden dividir entre servicios gratuitos o pagos.

Son normalmente contratos de adhesión, no negociados individualmente.

Contrato de Housing.

Es un contrato en virtud del cual una empresa dedicada a la prestación de servicios informáticos se compromete a ubicar en sus instalaciones un determinado hardware propiedad del cliente y a prestar al cliente una serie de servicios adicionales como el mantenimiento del hardware, a cambio de un precio. El equipamiento es propiedad del cliente, que la compra, configura y mantiene (existe libertad para la instalación de programas y aplicaciones).

El proveedor del servicio normalmente brinda energía eléctrica, aire acondicionado, accesibilidad a la red y seguridad.

Otros contratos:

- Contrato de procesamiento de datos.
- Contrato de ayuda on line.
- Contrato de formación y capacitación de usuarios.
- Contrato de acceso a Internet.
- Contrato de diseño de páginas web.
- Contrato de publicidad en Internet.
- Contrato de consultoría.
- Contrato de implantación de plan de seguridad.
- Contrato de auditoría de seguridad informática.
- Contrato de auditoría de calidad informática.
- Contrato de transferencia de tecnología o know-how.
- Contrato de instalación y actualización periódica de antivirus.
- Contrato de certificación de transacciones electrónicas.
- Contrato de gestión de redes.
- Contrato de teletrabajo.